Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vfaz@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5064251-74.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: CELIO THEODOLINDO DOS SANTOS FRANCO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

CELIO THEODOLINDO DOS SANTOS FRANCO ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de "Neoplasia maligna da parede posterior da orofaringe" (CID C10.3) e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Pembrolizumabe 200mg**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade da justiça e solicitada nota técnica (evento 7, DESPADEC1), sobreveio com conclusão favorável (evento 13, NOTATEC1).

Concedida a antecipação de tutela (evento 15, DESPADEC1).

O IPÊ-SAÚDE informou a emissão de autorização para o fármaco postulado (evento 21, OFIC1).

Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 29, CONT1).

A parte autora replicou (evento 32, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 37, DESPADEC1), o autor decorreu o prazo (Evento 40) e o demandado nada requereu (evento 43, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 46, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 15, DESPADEC1):

> *"(...) Observa-se que a negativa administrativa do IPE-SAÚDE (**Outros 7**) em fornecer o tratamento, através do uso da medicação postulada, baseia-se exclusivamente na alegação de que o medicamento 23441 não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia.*
>
> *Por sua vez, segundo o laudo médico que acompanhou a inicial (**Laudo 5**), a parte autora é portadora de carcinoma epidermóide de orofaringe, subtipo p16 positivo e PD L1 positivo (CID 10 C1.09). Explanou que o autor apresenta a doença em estágio avançado (estágio IV), com coportamento agressivo apresentando metástases hepáticas e ósseas. Atestou o médico que o demandante necessita do medicamento Pembrolizumabe (droga anti PD-1) para uso de forma associada à quimioterapia com imunoterapia. Referiu que o uso combinado das medicações, conforme estudo clínico, oferece aumento de sobrevida global e redução no risco de morte, bem como aumento na taxa de resposta. Destacou, ainda, a necessidade de iniciar o tratamento com brevidade sob o risco de progressão do câncer, o que pode provocar o óbito do autor.*
>
> *Ademais, a Nota Técnica emitida pelo DMJ apresentou **parecer favorável**, conforme transcrito abaixo.*
>
> > *"[...] Tecnologia: PEMBROLIZUMABE*
> >
> > *Conclusão Justificada: Favorável*

Conclusão: Considerando as evidências disponíveis na literatura e as informações contidas no laudo médico acostado, conclui-se que estão presentes elementos técnicos que justificam a indicação do medicamento e permitem sustentar parecer favorável ao tratamento pleiteado.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida [...]"

Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se a tratamento utilizando o medicamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Por fim, em que pese este juízo não desconheça que em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde, revogando a Lei Complementar n.º 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto, não é facultado ao plano escolher quais tratamento serão dispensados. Neste sentido:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.*

Assim, assegurado o direito da parte autora em ter a sua saúde resguardada, e comprovada a necessidade que possui em receber o tratamento pleiteado, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela pretendida.

***1.** Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** e determino ao IPE-Saúde que, no prazo de 10 (dez) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Pembrolizumabe 200mg**, nos termos da prescrição e laudo médico (**Laudo 5**), os quais deverão ser atualizados pela parte autora semestralmente.(...)"*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos, que indica possuir a parte autora diagnóstico de **"Neoplasia maligna da parede posterior da orofaringe" (CID C10.3)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Pembrolizumabe 200mg**. Da mesma forma, comprovada a **urgência** do tratamento devido ao risco de haver progressão da doença e óbito. Senão vejamos (evento 1, LAUDO5):

Laudo Médico

O Sr. Celio Theodolindo dos Santos Franco de 60 anos, CPF 3956677034 tem o diagnóstico de carcinoma epidermóide de orofaringe, subtipo p16 positivo, (relacionado a infecção pelo HPV) e PD L1 positivo, CID-10 C1.09. Apresenta doença em estágio avançado (estágio IV) com comportamento agressivo apresentando metástases hepáticas e ósseas ao diagnóstico.

Neste contexto, a melhor estratégia de tratamento é a combinação de quimioterapia com imunoterapia com uma droga anti PD-1 chamada Pembrolizumabe. Pembrolizumabe é um tipo de imunoterapia que age bloqueando uma proteína chamada PD-1 nas células imunes e assim consegue fazer com que o sistema imune reconheça e ataque as células cancerosas. A droga foi aprovada pela Anvisa e por demais agências regulatórias como o FDA e EMA para o câncer de cabeça e pescoço recorrente ou metastático. Também é aprovada como tratamento de primeira linha em tumores de cabeça e pescoço irressecáveis ou metastáticos que tem expressão de PL-L1 num escore positivo combinado (CPS) maior ou igual a um, como o paciente em questão.

A indicação deste tratamento baseia -se num estudo de fase III, randomizado, Keynote -048, conduzido em 37 países, com a participação de 882 pacientes. Este estudo comparou a combinação de Pembrolizumab e quimioterapia versus o tratamento padrão que consiste na combinação de Quimioterapia com uma droga denominada Cetuximabe. A adição da imunoterapia produziu aumento de sobrevida global de 10.7 para 14.9 meses e reduziu o risco de morte em 39 % no braço com pembrolizumabe. Também ocorreu aumento da taxa de resposta (redução do volume tumoral e da sobrevida livre de progressão (tempo que o paciente fica com a doença controlada), em relação ao tratamento com Cetuximabe.

Pembrolizumabe deverá ser administrado na dose de 200mg por vía endovenosa a cada 3 semanas concomitante à quimioterapia por 6 ciclos, e posteriormente de maneira isolada, a cada 3 semanas por até 35 ciclos (2 anos de tratamento ao todo) se não ocorrer progressão da doença ou toxicidade grave com a droga.

Este tratamento deverá ser iniciado com brevidade sob o risco de progressão do câncer o que pode provocar o óbito da paciente.

Ademais, sobreveio nota técnica com parecer favorável (evento 13, NOTATEC1):

Conclusão

Tecnologia: PEMBROLIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando as evidências disponíveis na literatura e as informações contidas no laudo médico acostado, conclui-se que estão presentes elementos técnicos que justificam a indicação do medicamento e permitem sustentar parecer favorável ao tratamento pleiteado.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Com efeito, o(a) médico(a) assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo(a) médico(a) assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por CELIO THEODOLINDO DOS SANTOS FRANCO em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Pembrolizumabe,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo(a) médico(a) assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 19/11/2023, às 16:22:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10049678041v4** e o código CRC **a792ab67**.